

TEORIA GERAL DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Nem sempre os editais preverão expressamente a cobrança da Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais, normalmente não há essa previsão.

Contudo, quando há no edital a previsão da cobrança do Título II – Direitos e Garantias Fundamentais, implicitamente está sua teoria geral, razão pela qual é necessário enfrentar esse assunto, especialmente para concursos de maior grau de dificuldades.

Caso não haja previsão expressa de cobrança no edital, não quer dizer que não é preciso estudar. Caso o conteúdo programático da prova preveja a cobrança do Título II da Constituição (Direitos e Garantias Fundamentais), o examinador pode cobrar sua teoria geral, porque isso está implícito.



O Título II – Direitos e Garantias Fundamentais, compõe um gênero, cujas espécies são os capítulos desse título: Capítulo 1 – Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo 2 – Direitos Sociais; Capítulo 3 – Nacionalidade; Capítulo 4 – Direitos Políticos; e Capítulo 5 – Partidos Políticos.



PEGADINHA DA BANCA

Isso pode parecer irrelevante, mas não é, uma vez que já foi cobrado em provas: a banca afirmou que os Direitos e Garantias Fundamentais englobam apenas os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e os Direitos Sociais.

A afirmação está errada, uma vez que o Título II – Direitos e Garantias Fundamentais, é um gênero, que engloba os seus cinco capítulos: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Direitos Sociais, Nacionalidades, Direitos Políticos e Partidos Políticos.

Muito embora o Título II se chame Direitos e Garantias Fundamentais, isso não significa que esse título esgota os Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição, porque não esgota.

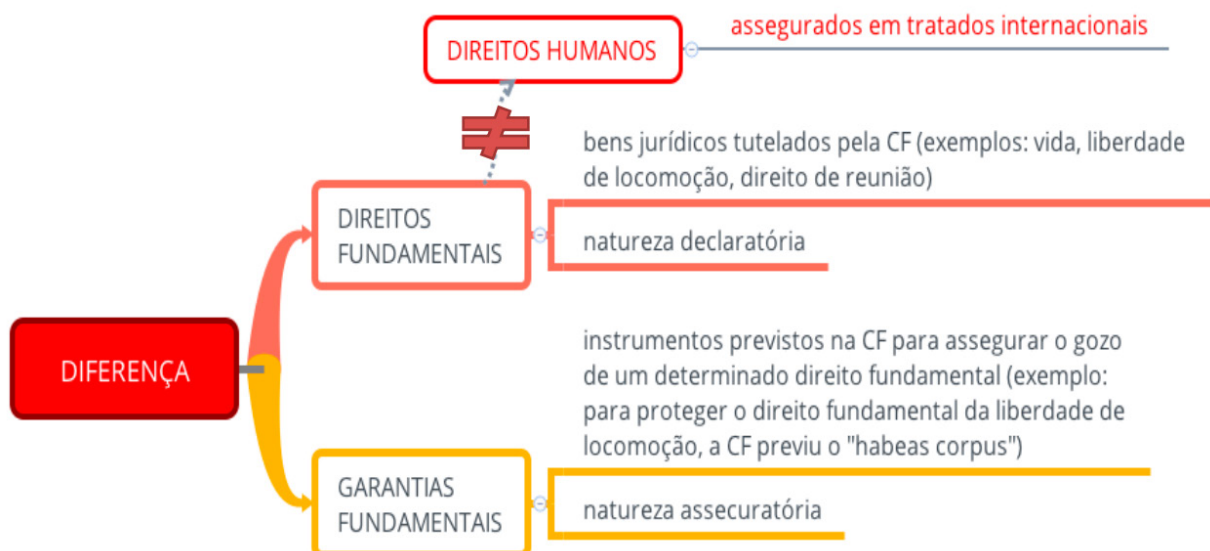
O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, já afirmou que os Direitos e Garantias Fundamentais estão espalhados pela Constituição Federal, não apenas no Título II. É bem verdade que o Título II prevê uma grande parcela deles, mas não apenas, uma vez que eles podem ser encontrados em qualquer parte da Constituição Federal.

Exemplo: no Título VIII – Ordem Social, é possível extrair diversos direitos fundamentais, como o art. 225, em que a Constituição assegura a todos o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, embora seja um direito fundamental, não está previsto no Título II.

O Título VIII prevê ainda o direito ao acesso à cultura, desporto, proteção da família, proteção da criança, do adolescente e do idoso.

No Sistema Tributário Nacional, que é estudado em Direito Tributário, também há direitos fundamentais, como a proibição da bitributação e preservação da capacidade contributiva, que são exemplos.

O importante nessa aula sobre a Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais é saber que o Título II não esgota os direitos e garantias fundamentais na Constituição, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se espalhados por toda a Constituição.



DIFERENÇA ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

É necessário abordar a diferença entre direitos e garantias fundamentais, que não são sinônimos, uma vez que se o fossem, o Título II se chamaria apenas Direitos Fundamentais ou apenas Garantias Fundamentais, mas não é assim. O nome jurídico do Título II é Direitos e Garantias Fundamentais, porque os termos não se equivalem, ao contrário, são diferentes.



Os direitos fundamentais são os próprios bens jurídicos protegidos pela Constituição Federal. São direitos tão importantes para a sociedade brasileira que são tutelados pela Constituição, que é a norma maior do ordenamento jurídico.

O artigo 5º, em seu *caput*, já prevê cinco direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, mas existem diversos outros, como o direito de reunião, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de imprensa e liberdade de crença.

Os direitos fundamentais são aqueles que são declarados pela própria Constituição Federal, existe essa natureza declaratória. A Constituição prevê quais são os direitos fundamentais, que são direitos tão importantes para a comunidade que são protegidos pela norma mais importante que é a Constituição Federal.

Por outro lado, as garantias fundamentais têm um caráter assecuratório/ instrumental: as garantias não possuem um fim em si mesmas, mas existem para proteger um determinado direito.

Exemplo é a liberdade de locomoção: o direito de ir, vir e permanecer no território nacional com seus bens, previsto no art. 5º, é um direito fundamental declarado pela Constituição Federal. Se houver uma ilegalidade ou abuso de poder que ameace/prejudique o exercício da liberdade de locomoção, a própria Constituição prevê uma garantia, o habeas corpus, que tutela/protege a liberdade de locomoção.

A liberdade de locomoção é um direito fundamental e a Constituição previu uma garantia fundamental para protegê-la.

Direitos fundamentais são os bens jurídicos tutelados pela própria Constituição, de natureza declaratória, porque a Constituição os declara. Já as garantias fundamentais têm esse caráter instrumental/assecuratório, que visa assegurar/proteger um determinado direito fundamental.

Os direitos fundamentais são os próprios bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal.



PEGADINHA DA BANCA

A diferença quanto à natureza jurídica dos direitos e garantias fundamentais já foi cobrada em provas: a questão afirma que o direito fundamental tem natureza assecuratória, o que está errado, uma vez que possui natureza declaratória. Quem tem natureza assecuratória é a garantia fundamental.

DIFERENÇA ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS

A diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos está ligada ao diploma legal que os prevê: os direitos fundamentais estão tutelados pela Constituição Federal (se está previsto na Constituição Federal, de forma declarada por ela, é um bem jurídico previsto nela e é um direito fundamental).



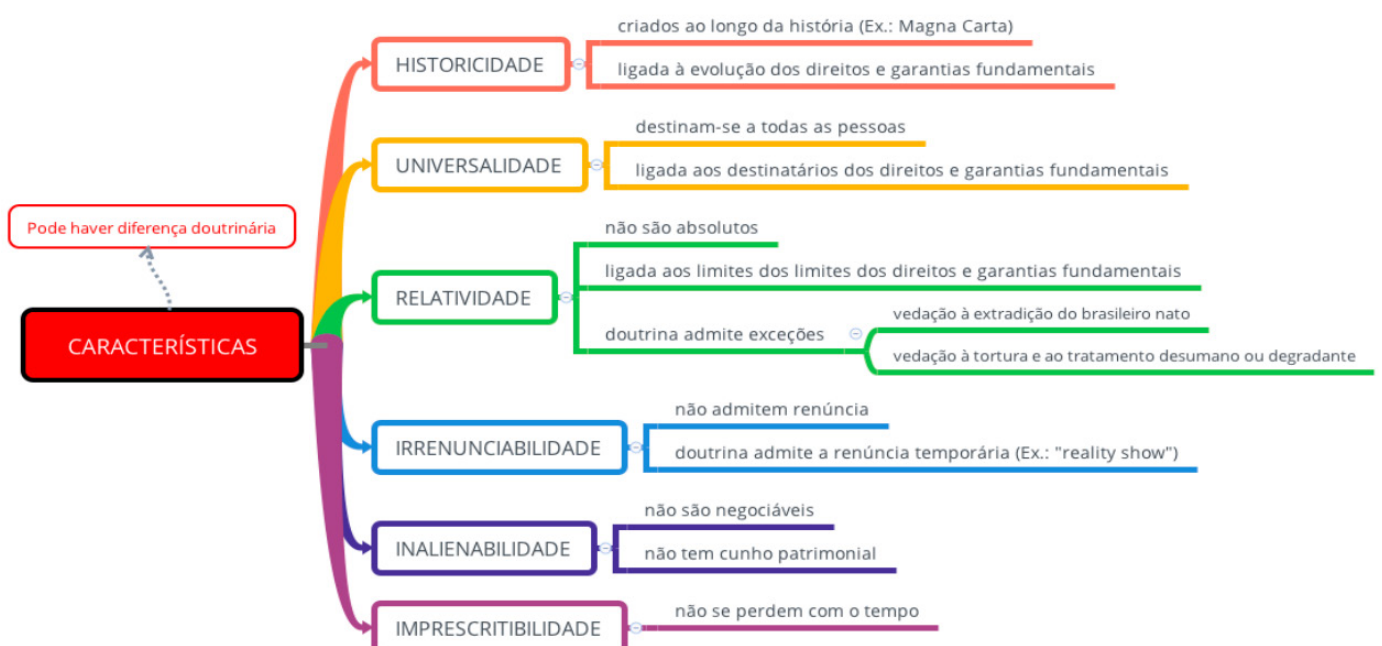
Por outro lado, os direitos humanos são previstos em tratados internacionais. Para que um direito humano se transforme em um direito fundamental, precisa estar dentro da Constituição Federal. Caso não esteja dentro da Constituição Federal, mas o Brasil tenha assinado um tratado na órbita internacional, é caracterizado como direito humano.

Direito humano é uma matéria própria. Quando, por exemplo, no edital de carreiras policiais é prevista a cobrança de direitos humanos, o professor de direitos humanos o ensina, se pautando nos tratados internacionais sobre direitos humanos.

Quando o tratado internacional sobre direitos humanos é internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, pelo rito do art. 5º, § 3º, ou seja, por dois turnos, nas duas casas do congresso, por três quintos dos votos, assume caráter de direito fundamental, porque se incorpora na Constituição.

De forma simples e objetiva, para ser direito fundamental, precisa estar na Constituição Federal. Se o direito não é previsto na Constituição Federal, mas está em um tratado internacional sobre direitos humanos, é um direito humano.

CARACTERÍSTICAS



Não há uma convergência única na doutrina com relação a quais são as características. Pode ser que um determinado doutrinador apresente outras, mas o importante é saber as seis que serão abordadas nesta aula, que são importantíssimas, porque costumam ser cobradas nas provas.

Trata-se das seguintes características: historicidade, universalidade, relatividade (é uma das características mais importantes), irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.

HISTORICIDADE

A Historicidade está ligada a outro assunto da teoria geral, a evolução dos direitos e garantias fundamentais em primeira, segunda e terceira gerações, e para alguns doutrinadores, ainda há a quarta e quinta geração.

A historicidade dos direitos e garantias fundamentais significa que eles foram surgindo ao longo da história da humanidade: desde a magna carta libertatum, que data de 1215, são previstos direitos e garantias fundamentais para o ser humano, assim como a carta assinada pelo rei da Inglaterra, João Sem Terra, atribuindo para o povo inglês direitos fundamentais.

Isso mostra que a previsão de direitos fundamentais em um diploma jurídico é bastante antiga.

Os direitos e garantia fundamentais foram criados ao longo da história da humanidade, não foram criados, por exemplo, todos em 1988, com a publicação do ato de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

UNIVERSALIDADE

A universalidade significa que os direitos e garantias fundamentais se destinam a todas as pessoas.

O assunto será aprofundado quando forem abordados os destinatários dos direitos e garantias fundamentais, momento em que será afirmado que se destinam a todas as pessoas, desde que o direito seja compatível com a sua natureza.

A Constituição prevê direitos e garantias fundamentais que apenas se destinam, por exemplo, a brasileiros natos, que é a proibição absoluta da extradição, por exemplo. Por outro lado, quando se trata da proibição para os brasileiros naturalizados, é previsto que eles podem ser extraditados por crime comum praticado antes da naturalização ou por envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Existem direitos fundamentais para os estrangeiros, como o de não poderem ser extraditados se cometerem crime político/de opinião.



15m

As pessoas jurídicas também são destinatárias dos direitos fundamentais, na medida da sua natureza jurídica: o STJ reconhece a possibilidade de condenação por perdas e danos, caso seja ferida a honra objetiva da pessoa jurídica.

Como característica dos direitos e garantias fundamentais, é necessário lembrar que eles estão previstos na Constituição e se destinam a todas as pessoas (físicas, jurídicas, nacionais, estrangeiras), à universalidade, que é uma universalidade relativa, porque o direito tem que ser compatível com a sua natureza.

RELATIVIDADE

Os direitos e as garantias fundamentais não são absolutos.

Também há um assunto da Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais que trata do limite dos limites dos direitos e garantias fundamentais: é possível limitar, mas essa limitação encontra limite no princípio da proporcionalidade.

A regra é que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, mas relativos. Mas existem direitos absolutos, como, por exemplo, a proibição à extradição do brasileiro nato, que não comporta exceção, é um direito absoluto. Outro exemplo, é a proibição à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. Dentro do escopo do atual Estado Democrático de Direito, não se permite a tortura ou tratamento desumano ou degradante, de maneira nenhuma.

A vida, que é o direito mais elementar, é relativa, porque a própria Constituição Federal admite pena de morte, no caso de guerra externa declarada. A própria Constituição traz uma exceção ao direito à vida, autorizando a pena de morte, no caso de guerra externa declarada.

A característica dos direitos e garantias fundamentais é que são relativos. Mas, excepcionalmente, é possível citar alguns direitos que são absolutos.

IRRENUNCIABILIDADE

A irrenunciabilidade significa que os direitos e garantias fundamentais não podem ser renunciados, não admitem renúncia, como regra.

A doutrina prevê uma possibilidade excepcional de renúncia temporária, como ocorre nos reality shows: quando a pessoa participa de um reality show, abre mão, temporariamente, do seu direito à intimidade, privacidade e vida privada, permitindo que o programa de TV mostre para o público o seu dia a dia.

Trata-se de uma possibilidade temporária e para certas partes da vida íntima da pessoa.

A regra é a irrenunciabilidade, porque o direito e garantia fundamental que está previsto na Constituição Federal, se incorpora ao patrimônio jurídico da pessoa e ela não pode o renunciar, não possui esse direito de renúncia.



20m

INALIENABILIDADE

Os direitos e garantias fundamentais não são negociáveis, não possuem cunho patrimonial. Ninguém pode vender a própria vida, alugar sua saúde ou vender um órgão. São direitos que o ser humano possui, que não estão no mundo jurídico, em regra.

O direito à propriedade está no mundo dos negócios. Contudo, as características abordadas são gerais e os direitos fundamentais não possuem valor patrimonial, não são negociáveis.

Não se pode negociar a liberdade de locomoção ou dar em comodato a própria liberdade de crença. São direitos fundamentais previstos na Constituição que se incorporam ao patrimônio jurídico da pessoa e não podem ser por ela negociados, como regra.

IMPRESCRITIBILIDADE

Os direitos e garantias fundamentais possuem a característica da imprescritibilidade, o que significa que eles não se perdem com o decurso do prazo, com o passar dos tempos.

A Constituição prevê o direito fundamental à saúde pública: todos têm direito à saúde, todas as pessoas físicas que estão no território brasileiro possuem o direito à saúde, de tal sorte que a pessoa pode, a qualquer momento, bater à porta do SUS – Sistema Único de Saúde, e terá direito à assistência à saúde, independentemente de contribuição.

Um estrangeiro/turista, que está no território brasileiro e sofre um acidente, será conduzido para um hospital público para ser assistido pelo Sistema Público de Saúde, porque é um direito de todos.

A pessoa jurídica não tem direito à saúde.

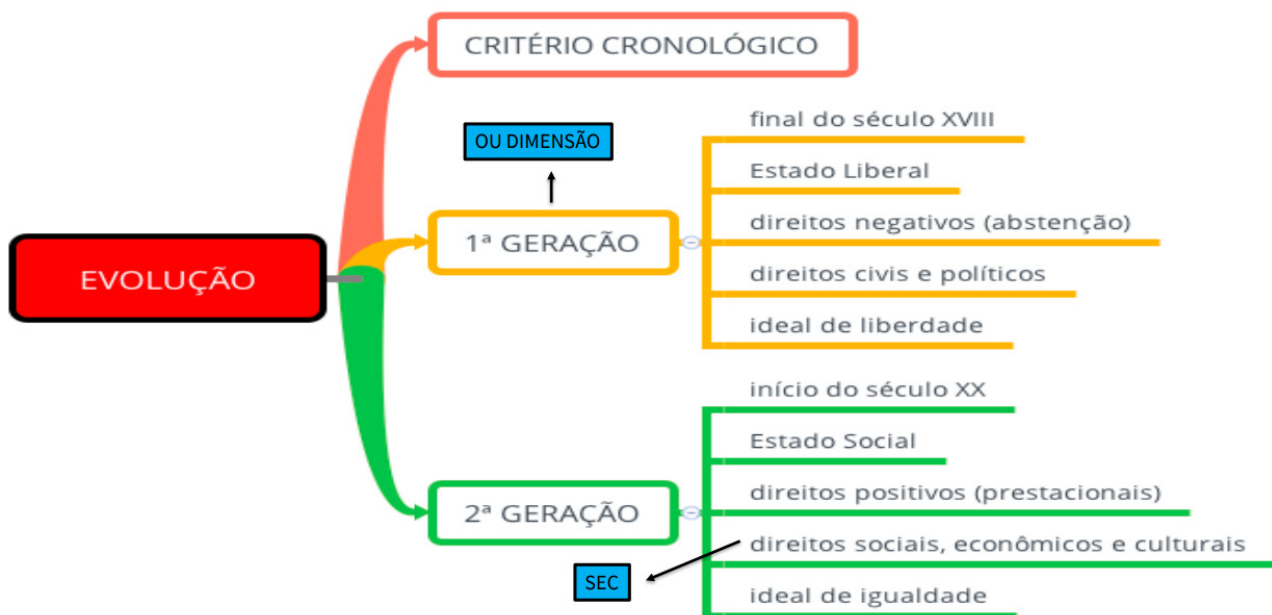
Uma pessoa que tem condições de pagar um plano de saúde privado, enquanto o tem, não usa o SUS. Mas, caso o infortúnio, ocorra daqui a 30 anos e ela precise do Sistema Público de Saúde, poderá usar, porque os direitos fundamentais não se perdem com o decurso do tempo.

O fato de atualmente a pessoa não precisar do Sistema Único de Saúde não significa que posteriormente não possa utilizar desse direito fundamental.



25m

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS



A evolução dos direitos e garantias fundamentais está umbilicalmente ligada com a historicidade.

De forma introdutória, é importante dizer que alguns doutrinadores preferem o termo dimensão ao termo geração. A grande maioria da doutrina usa o termo geração dos direitos fundamentais: primeira geração, segunda geração e terceira geração. Contudo, o termo geração pode conduzir a uma interpretação equivocada.

No dia a dia, quando se pensa em geração, pensa-se em substituição. Exemplo é a seleção brasileira teve a geração de 1970 e hoje tem uma nova geração. Quando se apresenta essa informação, se pensa automaticamente que a geração de 1970 não joga mais e foi substituída pela geração atual.

No dia a dia, o termo geração tem essa conotação de substituição da anterior pela posterior. Contudo, isso não ocorre quando se trata de direitos e garantias fundamentais: existia a primeira geração, depois surgiu a segunda geração que se somou à primeira, depois surgiu a terceira geração que se somou às demais.

A ideia é de cumulatividade, não de substituição, mas de cumulação/coexistência dos direitos e garantias fundamentais.

A partir dessa ótica, alguns preferem usar o termo dimensão para que não se tenha a ideia equivocada de substituição, porque não é.

Para provas de concurso público, geração e dimensão de direitos fundamentais são a mesma coisa, é apenas uma questão de nomenclatura.

O critério utilizado pela doutrina é cronológico, que significa o momento da história em que o direito foi reconhecido como fundamental e incorporado ao patrimônio jurídico da humanidade: a primeira geração, no final do século XVIII; a segunda geração, no início do século XX; e a terceira geração, no decorrer do século XX.

A existência da primeira, segunda e terceira geração é uníssona, não há discussão, que reside na existência ou não da quarta e quinta geração.

Geralmente são cobradas a primeira, segunda e terceira geração, pois são reconhecidas por todos.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Luciano Pereira Dutra.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
